UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

NOVA GRADUAÇÃO UNIVERSIDADE LA SALLE

UNIDADE 4

Direito DIGITAL

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA

unidade
4
V.1 | 2023

Acesso e Proteção à Informação e Dados

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Conhecer os principais mecanismos legais de proteção à informação, em seus diversos aspectos.

Editora LaSalle

unidade
4
V.1 | 2023

Parte 1

A Legislação Sobre a Segurança da Informação no Brasil

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

A legislação sobre a segurança da informação no Brasil

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil.
- Identificar os direitos do titular dos dados e os deveres de agentes e controladores.
- Analisar os impactos da LGPD para o *big data* e as operações das empresas.

Introdução

A Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), é um grande marco legal brasileiro. Ela traz diversos impactos para as instituições privadas e públicas, justamente por tratar da proteção dos dados pessoais dos indivíduos em qualquer transação comercial, seja de pessoa física ou jurídica. Essa regulamentação tem três pilares: princípios, direitos e obrigações. Esses pilares dão sustentação aos ativos mais valiosos de uma sociedade digital, que são as bases de dados relacionados às pessoas.

Neste capítulo, você vai verificar a importância da LGPD e descobrir de que forma ela foi concebida, além de conhecer os seus conceitos, a sua terminologia e a sua aplicabilidade. Você ainda vai ver um comparativo entre a LGPD e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), elaborado pela União Europeia. Por fim, você vai conhecer os impactos da LGPD para o *big data* e para as operações do dia a dia das empresas.

Importância da LGPD

A LGPD foi promulgada pelo então presidente Michel Temer no dia 14 de agosto de 2018 e se originou do Projeto de Lei da Câmara nº. 53, de 2018. Trata-se de uma legislação muito técnica, que busca reunir uma série de controles a fim de assegurar o cumprimento das garantias do direito individual de cada cidadão, utilizando como premissa básica a proteção dos direitos humanos.

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, terão um tempo para se adequar a essa normativa, que se aplica a empresas de qualquer porte ou segmento de mercado. Após a adequação, as empresas estarão sujeitas ao rigor das penalidades da lei, que também variam de acordo com o tipo de situação e com o porte financeiro da organização.

A LGPD foi amplamente inspirada no RGPD, vigente na União Europeia. Portanto, ela leva em conta os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento das relações entre as pessoas, tendo como princípio a boa-fé. Ou seja, busca-se a transparência: o cidadão deve ter total conhecimento da forma como o seu registro será tratado pela outra parte envolvida na transação de dados.

A LGPD, conforme Pinheiro (2018), é mais enxuta em alguns pontos quando comparada ao RGPD, criando também espaços para interpretações, o que deixa tudo mais subjetivo. Isso pode gerar insegurança jurídica, justamente pela falta de objetividade. Em relação aos prazos, por exemplo, enquanto a norma europeia determina que dada ação seja feita em até 72 horas, a LGPD apenas menciona um "prazo razoável". Mas o que é um prazo razoável? Como você pode imaginar, esse tipo de situação dará origem a diversos debates jurídicos no futuro.



Saiba mais

A LGPD está dividida em 10 capítulos e têm 65 artigos. Comparativamente, ela é menor do que o RGPD, que possui 11 capítulos e 99 artigos.

Outro ponto relevante vinculado à LGPD é a criação do órgão regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Veja o que diz a lei (BRASIL, 2018, 2019):

> Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.
> § 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República.
> § 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD.
> § 3º O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias.

Apesar das boas intenções do RGPD, essas diretrizes impostas pela União Europeia exigem a adaptação de todos os países que possuem relação comercial com os signatários do bloco europeu. Nesse mesmo sentido, no caso do Brasil, um dos efeitos colaterais da LGPD é o aumento do chamado "custo Brasil". Isso ocorre devido à necessidade de todas as empresas do setor público e privado se adequarem à normativa, o que envolve a revisão de processos, a adaptação de sistemas e a realização de treinamentos junto às pessoas envolvidas nas atividades impactadas pela LGPD.



Saiba mais

"Custo Brasil" é uma expressão usada para descrever o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que encarecem o investimento no Brasil. Assim, esse custo dificulta o desenvolvimento nacional, aumentando o desemprego, o trabalho informal, a sonegação de impostos e a evasão de divisas.

Conceitos da LGPD

Nesta seção, você vai conhecer os principais conceitos e as principais terminologias utilizadas na LGPD. Esses elementos são fundamentais e estarão cada vez mais presentes no seu dia a dia, o que se deve à necessidade de adequar documentos e sistemas às novas políticas, normas, procedimentos e contratos (PINHEIRO, 2018).

- **Titular:** pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de algum tratamento.
- **Tratamento de dados:** toda operação realizada com algum tipo de manuseio de dados pessoais. Por exemplo: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, edição, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
- **Dados pessoais:** toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, não se limitando, portanto, a nome, sobrenome, apelido, idade, endereço residencial ou eletrônico. Podem incluir dados de localização, placas de automóvel, perfis de compras, número do Internet Protocol (IP), dados acadêmicos, histórico de compras, etc. São sempre relacionados a pessoa natural viva.
- **Dados pessoais sensíveis:** são dados relacionados a características da personalidade do indivíduo e às suas escolhas pessoais. Por exemplo: origem racial ou étnica; convicção religiosa; opinião política; filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político; dado referente à saúde ou à vida sexual; dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- **Dados anonimizados:** são os dados relativos a um titular que não pode ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento.
- **Anonimização:** utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Não é o único motivo que autoriza o tratamento de dados, mas apenas uma das hipóteses.

- **Agentes de tratamento:** o controlador que recepciona os dados pessoais dos titulares de dados por meio do consentimento ou por hipóteses de exceção, e o operador que realiza algum tratamento de dados pessoais motivado por contrato ou obrigação legal.
- **Encarregado:** pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional.
- **Transferência internacional de dados:** transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro.

Esses termos e expressões, conforme Pinheiro (2018), serão cada vez mais utilizados no mercado. Assim, é muito importante que você entenda o sentido deles, em especial para ler e interpretar a LGPD com mais precisão.

Aplicabilidade da LGPD

Toda negociação realizada com brasileiros — no sentido jurídico do termo — está sob a abrangência da LGPD. Veja na forma da lei (BRASIL, 2018, 2019):

> Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:
> I — a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
> II — a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou
> III — os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Dessa forma, a LGPD não está diretamente relacionada à cidadania ou à nacionalidade dos dados do cidadão e muito menos faz referência ao domicílio do indivíduo titular. Em contrapartida, a lei não se aplica quando o tratamento dos dados é usado para fins exclusivamente particulares e não econômicos, entre outras situações elencadas no art. 4º. Veja no texto decretado pelo Congresso Nacional (BRASIL, 2018, 2019):

> Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
> I — realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
> II — realizado para fins exclusivamente:
> a) jornalístico e artísticos; ou
> b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
> III — realizado para fins exclusivos de:
> a) segurança pública;
> b) defesa nacional;
> c) segurança do Estado; ou
> d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
> IV — provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

Atualmente, é evidente a necessidade de uma lei específica para o tratamento de dados. Afinal, a sociedade contemporânea é digital, de modo que o modelo de negócios vigente não possui fronteiras físicas e outros limites que eram comuns há algumas décadas. Por isso, hoje o conhecimento da LGPD é extremamente estratégico para as organizações que desejam entender o seu consumidor e ampliar os seus lucros de forma sustável. Em síntese, buscar conhecer o consumidor não é um problema; a questão é que isso deve ficar claro tanto para a empresa quanto para o usuário, ou seja, deve haver maior transparência em relação à forma como as transações de dados ocorrem.



Fique atento

A LGPD tem alcance extraterritorial, ou seja, atinge também empresas que estão no exterior, desde que o dado de origem tenha partido do Brasil. Por isso, uma empresa de computação em nuvem (*cloud computing*) que possui determinado registro fora do território nacional também precisa se adequar às exigências da LGPD.

Análise comparativa entre LGPD e RGPD

O tema da proteção de dados, conforme Pinheiro (2018), foi melhor absorvido pela União Europeia devido à homogeneidade do bloco e às transações realizadas pelos países-membros, entre os quais há cada vez menos fronteiras e maiores interesses econômicos. Isso possibilitou a criação de um único regulamento para a comunidade europeia. Como você já viu, tal regulamento serviu de parâmetro para a legislação de proteção de dados de diversos outros países, entre eles o Brasil.

Por aqui, a LGPD foi criada a partir do que a área jurídica chama de **Direito Comparado**. Por meio de uma matriz de comparação, buscou-se avaliar o quanto o RGPD era aderente às legislações nacionais. Com base nas diferenças identificadas, mapeou-se o esforço de lei necessário para o enquadramento correto. A seguir, você vai ver como a LGPD e o RGPD tratam de aspectos importantes relacionados à proteção de dados.

Dados pessoais e dados sensíveis

Estão em jogo a definição e a distinção entre dados pessoais e dados sensíveis. Tal conceituação busca delimitar os direitos e as informações protegidas pelo ordenamento jurídico.

- **LGPD:** define que dado pessoal é qualquer informação que identifique ou torne identificável a pessoa natural. Já dados sensíveis são dados pessoais sobre etnia, raça, crenças religiosas, opiniões políticas, dados genéticos/biométricos, além de informações sobre filiações da pessoa natural a organizações quaisquer.
- **RGPD:** adota os mesmos princípios e conceitos para realizar a distinção e a delimitação dos direitos relativos aos dados pessoais e dados sensíveis. Ademais, faz considerações acerca de dados genéticos, biométricos e relativos à saúde.

Consentimento do usuário

Diz respeito à obrigatoriedade do consentimento do usuário para a coleta de informações, bem como à limitação do tratamento do dado conforme a finalidade.

- **LGPD:** a coleta e o tratamento de dados só poderão ser realizados se o usuário (dono dos dados ou responsável legal, no caso de menores legais) der o seu consentimento. Todo agente deve apontar finalidade certa, garantida e justificável para o tratamento do dado. Além disso, deve garantir que ele será utilizado somente para tal finalidade.
- **RGPD:** prevê a necessidade de uso do dado conforme a finalidade apontada. Traz exceções de tratamento por motivo de interesse público, segurança e saúde.

Titularidade e responsabilidade

A questão aqui é a distinção entre titularidade e responsabilidade sobre os dados, assim como a delimitação das funções e responsabilidades assumidas no tratamento de dados.

- **LGPD:** titular é a pessoa natural a quem se referem os dados que são objeto de tratamento; por outro lado, o responsável é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que toma decisões sobre o tratamento de dados. Além do responsável, há o operador — a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados. Ambos os agentes são juridicamente responsáveis pela segurança e pela privacidade dos dados.
- **RGPD:** há a mesma distinção entre titularidade e agentes, mas os agentes são divididos em controlador e processador de dados. O controlador é quem realiza as decisões acerca do tratamento de dados; o processador, quem efetua o tratamento. Ambos são responsáveis pelo tratamento de dados.

Agente de proteção de dados

Está em jogo a indicação de um encarregado pela comunicação entre os agentes, titulares e órgãos competentes.

- **LGPD:** além dos agentes, aponta-se a necessidade da indicação de um encarregado — pessoa natural — pela comunicação de qualquer informação ou fato relevante em relação ao tratamento dos dados. Ele deve atuar como um canal entre os agentes, titulares e órgãos competentes e deve ser indicado pela organização responsável pelo tratamento. Esse encarregado é chamado de "agente de proteção de dados".
- **RGPD:** aponta que o controlador deve ter uma pessoa responsável por tudo que se relacione à proteção de dados. Tal profissional é chamado de Data Protection Officer (DPO).

Transparência

Trata-se da aplicação de mecanismos e práticas pautadas no livre acesso à informação e na transparência entre os usuários e as organizações.

- **LGPD:** do consentimento para o fornecimento de dados ao término desse tratamento, as informações acerca do processo devem ser claras, acessíveis e adequadas à linguagem e à compreensão do usuário, de forma que o seu consentimento possa ser revogado a qualquer momento. O consentimento do usuário deve ser realizado por escrito ou de qualquer outro modo que demonstre a livre manifestação da sua vontade.
- **RGPD:** os titulares também têm direito a informações claras e acessíveis do início ao fim do tratamento do dado, podendo revogar o consentimento a qualquer momento.

Segurança

Aqui, está em pauta a aplicação de medidas de segurança e o dever de reportar.

- **LGPD:** da mesma forma que as organizações são responsáveis no caso de incidentes (como vazamentos), no tratamento dos dados, elas devem aplicar medidas de prevenção e proteção à segurança dos dados que manuseiam, como anonimização e encriptação das informações. No caso de qualquer incidente, é obrigação da organização notificar as autoridades imediatamente.
- **RGPD:** também aponta que as empresas devem criar medidas — como pseudoanonimização e encriptação de dados — para garantir a segurança de forma preventiva. No caso de qualquer incidente, a notificação às autoridades deve ser imediata.

Alteração e exclusão do dado

Diz respeito às possibilidades de alteração e exclusão do dado pessoal.

- **LGPD:** o titular do dado pode alterar ou excluir o seu dado pessoal a qualquer momento, exceto nas hipóteses previstas na lei, como fins fiscais. Da mesma forma, assim que o tratamento de dados chegar ao final — seja porque cumpriu a sua finalidade, seja porque o usuário revogou o seu consentimento —, as informações devem ser eliminadas.
- **RGPD:** os titulares também podem alterar ou excluir os seus dados.

Penalizações

Trata-se da aplicação de sanções no caso de descumprimento das regras.

- **LGPD:** as punições incluem advertências, aplicação de multas, suspensão e até mesmo proibição das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Essas punições variam de forma gradativa de acordo com cada caso, com a gravidade do dano, com a condição econômica do infrator, com a reincidência, com a boa-fé do infrator, etc. O descumprimento de regras deve ser investigado por meio de um processo administrativo que assegura o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. As multas podem ser simples ou diárias, com valor relativo a 2% do faturamento da organização privada, limitadas a um total de 50 milhões de reais por infração.
- **RGPD:** também prevê a aplicação de sanções gradativas e multas administrativas, que podem chegar a 20 milhões de euros ou a 4% do faturamento anual da empresa.

Órgão fiscalizador

Aqui, está em jogo a criação de um órgão competente para fiscalizar e zelar pela proteção dos dados pessoais e da privacidade.

- **LGPD:** conforme o art. 55, foi criada a ANPD.
- **RGPD:** possui um órgão de controle e fiscalização de proteção de dados pessoais por Estado (28) e aplica o princípio do balcão único.

É possível verificar, conforme Pinheiro (2018), que existem diversas similaridades entre as duas leis, porém em alguns pontos o RGPD é mais abrangente e mais objetivo.



Fique atento

A melhor forma de analisar uma lei é pela verificação da conformidade dos itens de controle. Ou seja, se o controle não está presente, aplicado e implementado, o princípio não está sendo atendido.

Direitos do titular dos dados e deveres de agentes e controladores

Pinheiro (2018) destaca que a LGPD, assim como o RGPD, visa a fortalecer: a proteção da privacidade do titular dos dados; a liberdade de expressão, de informação, de opinião e de comunicação; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; e o desenvolvimento econômico e tecnológico. Quando o RGPD entrou em vigor, em 25 de maio de 2018, trouxe consigo os princípios que devem ser seguidos no cuidado e no trato dos dados pessoais:

- licitude;
- lealdade;
- transparência;
- limitação da finalidade;
- minimização dos dados;
- exatidão;
- limitação da conservação;
- integridade e confidencialidade (que são os mesmos da segurança da informação);
- responsabilidade.

Você já viu que a LGPD ressalta a boa-fé nas transações e no uso dos dados pessoais. Além disso, ela estabelece alguns princípios fundamentais para operação e legislação:

- finalidade do tratamento;
- compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular;
- limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades;
- garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma do tratamento;
- garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
- transparência aos titulares;
- utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais;
- prestação de contas, pelo agente, da adoção de medidas capazes de comprovar a proteção de dados pessoais.

Existem alguns pontos que precisam ser evidenciados para a aplicação correta dos princípios da LGPD no tratamento dos dados pessoais. O aspecto principal é que o titular saiba como e onde o seu registro será usado. No entanto, pode haver exceções. Por exemplo, um dado pode ser coletado sem consentimento expresso:

- para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
- quando necessário à execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
- para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;
- para a proteção da vida do titular ou de terceiros;
- quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros;
- para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.

Um dos pontos mais relevantes da LGPD é a necessidade de garantir os direitos do titular. As organizações devem ter um prazo razoável para o atendimento das necessidades do titular nas situações listadas a seguir:

- confirmação da existência de tratamento;
- acesso aos dados;
- correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei;
- portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
- eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
- informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- revogação do consentimento.

Penalidades da LGPD

Em relação às penalidades, algumas sanções da LGPD, conforme Pinheiro (2018), sofreram veto presidencial. Em suma, isso ocorreu para adequar as sanções à realidade brasileira. Assim, os valores das multas estabelecidas pela LGPD são menores do que os definidos pelo regulamento europeu. A seguir, veja algumas das penalidades previstas (BRASIL, 2018):

- advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
- multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a 50 milhões de reais por infração;
- multa diária, observado o limite total;
- publicização da infração após a sua ocorrência ser devidamente apurada e confirmada;
- bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
- eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

As penalidades listadas a seguir só serão aplicadas caso já tenha sido imposta ao menos uma das seguintes sanções: multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais. Veja:

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
- suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período;
- proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.



Fique atento

A LGPD não substitui a lei que versa sobre os direitos do consumidor.

Como pontua Pinheiro (2018), uma gestão adequada da proteção dos dados pessoais gera redução das penas, caso estas ocorram. Veja os parâmetros que podem ser utilizados na minimização de uma eventual punição por parte de uma autoridade fiscalizadora:

- a gravidade da infração;
- a boa-fé do infrator;
- a vantagem auferida;
- a condição econômica do infrator;
- a reincidência;
- o grau de dano causado;
- a cooperação do infrator;
- a demonstração de adoção de mecanismos e procedimentos para mitigar os danos;
- a adoção de política de boas práticas e governança;
- a pronta adoção de medidas corretivas;
- a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.



Fique atento

Para tornar o seu negócio sustentável ao longo do tempo, as organizações precisam atuar de acordo com os princípios da LGPD.

Impactos da LGPD

Como o mundo está cada vez mais digital, têm surgido diferentes funcionalidades e serviços capazes de armazenar, tratar e analisar uma quantidade enorme de dados. Com base nessas funcionalidades e serviços, é possível obter informações e posterior conhecimento para tomar decisões de maneira inovadora. Esse tipo de solução é chamado de *big data* (O QUE MUDA..., 2018).

Com essas novas possibilidades e o potencial de armazenamento, tratamento e análise de dados pessoais coletados a partir do uso diário das ferramentas digitais, tornou-se viável identificar padrões de comportamento e demais características pessoais. Da mesma forma, tornou-se possível antecipar ações e estabelecer perfis bastante detalhados dos usuários. Esse universo de possibilidades é hoje uma ferramenta de diferenciação no mercado, sendo muito utilizado pelas empresas que buscam entender os seus consumidores e maximizar os seus resultados.

O uso e a automatização desse tipo de processo são cada vez mais essenciais para grande parte do setor de Tecnologia da Informação (TI). Justamente porque a LGPD trata de dados no meio digital, se fez necessária uma ampla discussão para a elaboração dessa lei. Nesse contexto, a análise de dados parte do uso de algoritmos estruturados, ou seja, que atuam a partir de parâmetros preestabelecidos.

Esses parâmetros podem ser automatizados, gerando um tempo de resposta maior para a tomada de decisão. Ou seja, no mundo digital, existem diversos estudos que conseguem, a partir do *big data*, compreender melhor seus objetos, o que possibilita que as empresas ofereçam ao público final resultados mais adequados às suas necessidades. Por meio desses parâmetros, é possível definir, por exemplo, que anúncio será exibido para cada internauta, ou quem será a próxima pessoa a aparecer em um aplicativo de relacionamentos. Com essa massa de dados, é possível customizar totalmente a experiência do usuário.

A LGPD prevê, em seu art. 20, que titulares de dados pessoais podem solicitar a revisão das decisões automáticas quando estas afetarem os seus interesses. Portanto, o responsável pelo tratamento de tais dados é obrigado a fornecer, se solicitado pelo titular, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada.

Segundo a lei, o responsável pelo tratamento de dados só não será obrigado a fornecer critérios e procedimentos que possam revelar segredos comerciais e industriais. Assim, fica claro que a lei não traz prejuízos à estratégia de mercado da empresa. Muito pelo contrário: é possível gerar mais inteligência por meio da determinação do real motivo do uso de um dado. Assim, não se gera somente um grande cadastro, com registros que nunca serão usados, mas cria-se um banco de dados dinâmico e útil. Naturalmente, como você já viu, também está em jogo a preservação da boa-fé: é necessário deixar claro, durante uma transação, quais serão as consequências do compartilhamento dos dados; estando o titular ciente disso, ele pode aceitar ou não a proposta em questão.

A seguir, veja a íntegra do art. 20 da LGPS, que trata sobre os direitos dos proprietários dos dados (BRASIL, 2018, 2019):

> Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.
> § 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.
> § 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o "I" deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.

A tecnologia foi um dos grandes motivadores da criação das leis de proteção de dados por todo o mundo. Tais leis têm implicações diretas nas operações das empresas, que necessitam adequar os seus sistemas às novas normativas, buscando sempre incorporar as melhores práticas de *compliance* existentes.



Fique atento

Ao longo deste capítulo, você viu quais são os principais objetivos da LGPD. Você também conheceu os direitos do titular e as obrigações dos agentes e controladores em relação aos dados. Por fim, estudou os impactos tecnológicos aos quais as empresas têm de se adaptar. Como você verificou, para se adequarem à legislação, as organizações devem investir na proteção de dados.



Referências

BRASIL. *Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº. 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília: Casa Civil da Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709compilado.htm. Acesso em 24 abr. 2020.

BRASIL. *Lei nº. 13.853, de 8 de julho de 2019*. Altera a Lei nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. Brasília: Casa Civil da Presidência da República, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm. Acesso em 24 abr. 2020.

O QUE MUDA com a nova lei de dados pessoais. *LGPD Brasil*, São Paulo, ago. 2018. Disponível em https://www.lgpdbrasil.com.br/o-que-muda-com-a-lei. Acesso em 24 abr. 2020.

PINHEIRO, P. P. *Proteção de dados pessoais*: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São Paulo: Saraiva Jur, 2018. 112 p.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
4
V.1 | 2023

Parte 2

A Responsabilidade Civil dos Provedores a Partir do Marco Civil da Internet

O conteúdo deste livro é disponibilizado por SAGAH.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

A responsabilidade civil dos provedores a partir do Marco Civil da Internet

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar os princípios que disciplinam o uso da internet no Brasil.
- Descrever os direitos e garantias dos usuários da internet.
- Analisar a responsabilidade civil dos provedores de internet.

Introdução

A internet, criada em 1969, foi uma verdadeira revolução mundial. Se hoje você estuda *on-line*, paga contas com o aplicativo do seu banco, se comunica por mensagens de texto, faz compras sem sair de casa e se mantém informado por *sites* de notícias, além de outras coisas, é tudo devido ao advento da internet. Diante dessa revolução, surgiu a necessidade de analisar e impor regras, princípios e valores a fim de normatizar essa nova tecnologia e esse novo território. A partir daí, os mais diversos países criaram princípios e leis para disciplinar o uso da internet, incluindo o Brasil.

Neste capítulo, você vai estudar os princípios que disciplinam o uso da internet no Brasil, os direitos e garantias dos seus usuários e como se dá a responsabilidade civil dos provedores de internet.

Princípios reguladores da internet no Brasil

A internet surgiu nos Estados Unidos há mais de 50 anos, durante a Guerra Fria, em base militar. Após sua criação, a internet levou cerca de 20 anos para que se aproximasse do nível de tecnologia que conhecemos hoje, e foi na década de 1980 que houve de fato a criação da World Wide Web (WWW).

Atualmente, a internet representa o maior meio de comunicação do mundo, e seu advento suscitou uma nova mentalidade, com membros mais ativos e novos padrões de comportamentos. Com essas novas dinâmicas, surge a necessidade de regulamentação.

No Brasil, a primeira conexão realizada por meio da internet foi estabelecida pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) em 1988. Inicialmente, a conexão servia basicamente para troca de *e-mails* e envio de arquivos.

> De fato, já há algum tempo a internet deixou de ser um simples meio de comunicação e não se comporta mais como um mero recurso de transmissão de dados. [...] Todavia, de forma não menos surpreendente, a internet se tornou palco e instrumento para os mais diversos tipos de atos ilícitos, das mais variadas formas (GARCIA, 2016, documento *on-line*).

A cada dia que passa, as pessoas têm se tornado mais dependentes do computador e da internet. Para muitas empresas, sem a internet não é possível que seus colaboradores trabalharem ou que uma fábrica produza. Além disso, o uso da internet cresceu enormemente nos últimos anos, em especial após a pandemia da covid-19.

É fato que a internet desburocratizou e agilizou cotidianos e quebrou barreiras. No entanto, apesar dos pontos positivos, a rede também promoveu o cometimento de crimes: ofensas e descriminação, pirataria, pedofilia, perda e roubo de dados, extorsões, estelionatos e *fake news*, entre tantos outros atos e infrações.

Assim, diante desse cenário, não se viu outra alternativa senão regulamentar o uso da internet. No Brasil, uma das primeiras leis criadas com esse objetivo foi a Lei nº 12.965/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet e ao Estado:

> O Marco Civil da Internet representa uma das primeiras iniciativas, com força de lei, apta a estabelecer princípios, diretrizes e preceitos gerais a serem aplicados à regulamentação do uso da internet no Brasil e representa uma iniciativa necessária e benéfica à sociedade, não obstante a grande controvérsia e as oposições sofridas ao longo de sua tramitação no Congresso Brasileiro (GARCIA, 2016, documento *on-line*).

O Marco Civil da Internet foi a primeira lei que impôs regulamentação sobre seu uso no Brasil. Conforme o inciso I do artigo 5º da Lei nº 12.965/2014, internet é (BRASIL, 2014, documento *on-line*): "[...] o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes".

No auge do seu pioneirismo, a referida lei estabeleceu no seu 3º artigo o total de oito princípios da internet. O primeiro princípio previsto pelo Marco Civil da Internet é o da **garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento**, ou seja, na internet todos são livres para se expressar e se comunicar como quiserem.

> Para o Marco Civil, a internet é a nova ágora grega ou fórum romano, uma praça virtual que reúne a todos que queiram se manifestar sobre a pólis ou o Estado. É o lugar da manifestação e da liberdade. A liberdade de expressão na internet, nesse sentido, é a dimensão extrínseca da democracia digital (GONÇALVES, 2017, p. 11).

A Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) estipulou que toda pessoa tem direito à liberdade de expressão e pensamento, sendo que nesse direito está inclusa a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, verbalmente ou por escrito (CONVENÇÃO..., 1992, art. 13). Também é princípio previsto no artigo 3º do Marco Civil da Internet a proteção da privacidade, prevista inicialmente na Constituição da República Brasileira como um direito fundamental.

O direito à privacidade diz respeito ao direito de uma pessoa reservar sua vida particular, privada e pessoal. Vale ressaltar que o Marco Civil da Internet separou a proteção à privacidade como um princípio distinto da proteção aos dados pessoais. O princípio de proteção aos dados pessoais previsto na Lei nº 12.965/2014 inicialmente foi criticado, pois sua previsão dependia de regulamentação por lei específica, ou seja, deixava a cargo de nova lei especificar a proteção de dados. No entanto, com a publicação e entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi solucionada essa situação, mas somente em parte, pois a própria LGPD também passou a depender de nova regulamentação pela Agência Nacional de Proteção de Dados.

Além disso, também se trata de um princípio previsto no Marco Civil da Internet (inciso IV, art.3º) a preservação e garantia da neutralidade de rede. De acordo com Victor Hugo Gonçalves (2017), a neutralidade de rede impede que, por meio de subterfúgios e artimanhas tecnológicas, os provedores de acesso à internet, empresas de telecomunicações e provedores de apli-

cações de internet possam ter controle indevido sobre os dados pessoais dos usuários de modo a influenciar no seu ir e vir virtual, nas escolhas que fazem, nos conteúdos que acessam e nas informações e conhecimento que recebem e produzem. Assim, a neutralidade de rede deve ser garantida e preservada para que todos os usuários da internet consigam acessá-la de maneira igualitária, impedindo que provedores analisem e monitorem dados para obstruir caminhos e dificultar acessos.

Isso nos leva a pensar na neutralidade de rede relacionada à proteção de dados pessoais. É sabido que nossos cliques, curtidas e mensagens estão sendo monitorados por provedores, empresas, aplicativos e redes sociais para nos influenciar e filtrar certos conteúdos. Assim, aplicativos e redes sociais monitoram nossos dados e informações, analisando-os para entender melhor nossos interesses.

Quando buscamos por uma palavra, próprio sistema de pesquisa da Google faz uma triagem para nos entregar nas primeiras páginas de resultados aquilo que mais se adequa ao nosso perfil. Resta então a reflexão: como fica a neutralidade de rede nesse aspecto? Estamos sendo influenciados e quem sabe obstruídos em nossos acessos, em nosso nosso ir e vir virtual?

Também é princípio previsto no Marco Civil da Internet a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Nesse caso, temos um ponto de bastante crítica quanto à lei, que não previu o que seria de fato esse conceito de estabilidade, segurança e funcionalidade da rede. Se formos pensar, a estabilidade pode ser garantida pelo acesso integral e frequente à internet, que deve ser estável, e pela manutenção da conexão do usuário em atividade. Mas como lidar com dias em que a internet está fora do ar? Como lidar com o bloqueio do uso de dados por operadoras de telefonia? São perguntas que o Marco Civil da Internet não responde objetivamente.

Por outro lado, a segurança e a funcionalidade devem ser garantidas aos usuários quanto à proteção em casos de ataques *hackers* e quanto à manutenção de estabilidade em seu acesso à internet. No entanto, em única regulamentação normativa do Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Norma nº 4/95, artigo 41, determinou apenas que cabe aos provedores de internet o controle de segurança da conexão e outros.

> Assim, os usuários estão totalmente jogados à sua ignorância técnica e, principalmente, à mercê das práticas abusivas por parte das empresas de telecomunicações, que somente fornecem 10% da velocidade contratada, limitam o tráfego de dados e, até recentemente, obrigavam a contratação de provedor de acesso à internet, quando, de fato, elas mesmas faziam este serviço (GONÇALVES, 2017, p. 27).

O sexto princípio previsto na Lei nº 12.965/2014 trata do princípio da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades. O Marco Civil da Internet não exprime especificadamente quais agentes devem ser responsabilizados, utilizando-se do termo genérico para tratar do assunto.

Outro princípio da lei é a preservação da natureza participativa da rede. Nesse aspecto, a internet representa uma rede participativa, bilateral, em que aquele que produz a informação pode interagir com aquele que recebe a informação, ao contrário do rádio e da televisão, em que apenas aquele que produz a informação se comunica. Assim, na internet o usuário é participante ativo.

Por fim, o inciso VIII da Lei do Marco Civil da Internet trouxe como princípio a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet. Por esse princípio, desde que respeitados os direitos humanos fundamentais e as regulamentações já existentes, os negócios promovidos por meio da internet são livres.

Assim, o Marco Civil da Internet estipulou ao todo oito princípios norteadores do uso da internet no Brasil, não excluindo, todavia, aqueles já existentes em legislação brasileira ou internacional a qual o Brasil tenha aderido. Embora não tão esclarecedores, os princípios instaurados pela Lei nº 12.965/2014 são, além de pioneiros, de extrema importância para nortear o direito dos usuários da internet, garantindo que premissas básicas sejam respeitadas por provedores e empresas de telecomunicações.

Direitos e garantias dos usuários da internet

Os artigos 7º e 8º do Marco Civil da Internet trazem alguns direitos e garantias aos usuários da internet. No entanto, essa previsão não exclui dos usuários os demais direitos previstos em outras legislações, como é o caso da legislação consumerista. Além disso, são artigos apenas ampliativos e exemplificativos desses direitos.

Conforme o *caput* do artigo 7º da Lei nº 12.965/2014, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania (BRASIL, 2014). Assim, é direito de todo cidadão brasileiro o acesso à internet. É importante ressaltar, todavia, que o referido *caput*, como toda a legislação do Marco Civil da Internet, trouxe termos genéricos, não especificando como se dá o direito ao acesso à internet por pessoas mais carentes, população de baixa renda ou portadores de deficiência. Ora, tratando-se de um direito de todo cidadão brasileiro, o

acesso à internet deveria ser garantido à todos, inclusive os mais humildes ou que demandam necessidades especiais.

Em relação aos incisos do artigo 7º, são direitos dos usuários da internet: a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; e a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial (BRASIL, 2014). Aqui, em consonância com o princípio da privacidade previsto no artigo 3º da mesma lei, temos que as ações do usuário na internet devem ser protegidas e mantidas privadas, pois fazem parte de sua vida pessoal.

Também é direito dos usuários da internet a não suspensão da conexão à internet e a manutenção da qualidade contratada de conexão. Ademais, como mencionado, a neutralidade de rede deve ser preservada, ou seja, é direito do usuário manter a conexão de internet conforme a velocidade e a qualidade contratadas.



Exemplo

A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em recente decisão, entendeu que cabe danos morais diante da impossibilidade de utilização dos serviços de internet.

> APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERNET – BLOQUEIO INDEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – A impossibilidade de utilizar os serviços de internet, em razão de falha da operadora e bloqueio indevido, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais serviços são fundamentais na seara profissional, pessoal e de comunicação do consumidor. A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano. Assim, cabe ao magistrado, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização (MINAS GERAIS, 2020, documento *on-line*).

É ainda direito dos usuários da internet receber informações claras e completas dos contratos de prestação de serviços. Os contratos devem especificar hipóteses de proteção ao registro de conexão e aos dados pessoais, além de especificar como se dará o gerenciamento da qualidade de internet fornecida.

Somado a isso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) também prevê que os provedores de conexão e aplicação de internet devem informar adequadamente aos consumidores acerca dos diferentes produtos e serviços, especificando corretamente a quantidade, características, composição, quali-

dade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (BRASIL, 1990).

Nesse âmbito, o artigo 8º do Marco Civil da Internet traz em seus incisos hipóteses de nulidades de cláusulas contratuais, como as que impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet, ou que, em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil (BRASIL, 2014).

Diante do princípio da proteção de dados, são direitos dos usuários:

- o não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de dados de acesso a aplicações da internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;
- o recebimento de informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais;
- consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, o que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;
- exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas no art. 7º, incisos VII a X, da Lei nº 12.965/2014.

Os direitos elencados estão em consonância com a proteção de dados pessoais e são complementados com o previsto posteriormente na LGPD. Essa lei trouxe a necessidade de fornecimento de informações claras, simples e de fácil compreensão pelas empresas quanto ao tratamento de dados pessoais aos seus clientes e hipóteses em que tais dados poderão ser coletados desde que observados alguns princípios de finalidade, transparência, segurança e adequação do tratamento.

A LGPD reafirma ainda o que o Marco Civil da Internet previu: a necessidade de um consentimento claro, expresso e específico. O consentimento deve vir destacado no contrato. Nesse sentido, a LGPD também prevê que o ônus de prova a respeito do consentimento será sempre da empresa.

Um termo de consentimento bem elaborado deverá apresentar de forma muito clara e muito específica o motivo pelo qual dados serão coletados, por que e por quanto tempo. Os dados tratados devem ser usados para a

finalidade prevista no consentimento, caso contrário o consentimento poderá ser considerado nulo.

Ademais, o próprio Marco Civil determina, em seu art. 7º, inciso VIII, que os provedores deverão informar claramente aos usuários quanto ao tratamento e proteção de seus dados pessoais, utilizando-os apenas para fins que justifiquem sua coleta, que não sejam vedados pela legislação e que estejam especificados nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet (BRASIL, 2014).

Além do mais, os dados não poderão ser mantidos na base de dados da empresa provedora eternamente. Aqui temos uma norma que pode ser prejudicial a profissionais de tecnologia da informação que estudaram anos para compor e se aprofundar em matérias de banco de dados. No entanto, a lei é clara e, em conjunto com a LGPD, não permite o arquivamento dos dados dos usuários para sempre. Trata-se de uma norma que incentiva mais uma vez a proteção dos dados pessoais. Assim, havendo o término da relação entre usuários e provedor, por exemplo, os dados de cada usuário deverão ser eliminados da base de dados ou no mínimo transferidos (com autorização do usuário) a outra empresa contratada.

Em complemento à proteção de dados pessoais, também é direito do usuário, conforme previsto no art. 7º, inciso XI, do Marco Civil da Internet, a divulgação clara de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet (BRASIL, 2014). Ou seja, os provedores devem instituir políticas de privacidade e disponibilizá-las aos usuários para que conheçam detalhadamente a política de uso dos dados adotada. Tais políticas de privacidade nada mais são que um documento, um contrato, no qual a empresa divulga ao cliente, de forma simples e clara, quais são os dados coletados a seu respeito, quando são coletados, por quais motivos e o que é feito com esses dados.

Também é direito do usuário previsto na Lei nº 12.965/2014 a acessibilidade, conforme suas características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais. Nesse ponto, retomamos o princípio da neutralidade de rede e o exercício da plena cidadania pelo usuário. Pessoas com deficiência, por exemplo, têm o direito de acesso à internet, que deve ser disponibilizada de forma a garantir sua utilização de maneira específica e adaptada às necessidades. De acordo com o censo de 2010 (IBGE EDUCA, [2021?]), ao todo temos no Brasil mais de 45 milhões pessoas com deficiência — e se a internet quebra barreiras, também deve quebrar barreiras a ponto de garantir igualdade para os portadores de deficiência.

> Para tanto, há que se estipular mecanismos necessários para promover a acessibilidade para as pessoas com deficiência às tecnologias de informação e comunicação. Muitos programas de computador já criam esses meios, por exemplo, ao lerem as páginas de sítios para pessoas com deficiência visual. Entretanto, são muitas as barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência que as forçam a ser excluídas digitalmente. Desde a falta de acesso à internet até falta de mecanismos que substituam os teclados, que seria necessário para as pessoas com os braços amputados. Deveria se fazer uma política direcionada para acessibilidade de todas as pessoas com deficiência, com o fulcro de construir espaços de inclusão digital dessas pessoas e inseri-las como atores da sociedade (GONÇALVES, 2017, p. 50).

Por fim, é direito dos usuários da internet que seja aplicado o CDC nas relações de consumo estabelecidas pela rede. Logo, quando se adquire um produto por *site* de consumo ou aplicativo, por exemplo, os mesmos direitos e normas aplicáveis ao consumidor que vai até a loja física serão aplicados no meio digital. O mesmo vale para a própria contratação do serviço de internet, ou seja, as normas do CDC são aplicadas na contratação do serviço e no relacionamento entre as partes.

Responsabilidade civil dos provedores de internet

Muito se discute sobre a responsabilidade civil dos provedores de internet. O artigo 18 do Marco Civil da Internet determina que "[...] o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros". (BRASIL, 2014, documento *on-line*).

Nesse sentido, o provedor de conexão à internet é aquele que atribui ao computador ou ao *smartphone* um caminho lógico, um caminho do endereço de IP para navegação na internet. Assim, o provedor não teria qualquer responsabilidade acerca do conteúdo gerado por terceiros.

Imagine, por exemplo, que alguém seja vítima de *cyberbullying* pelo Facebook. Como qualquer uma empresa provedora poderia controlar o conteúdo gerado por terceiros em redes sociais? Como responsabilizá-la? Portanto, o provedor de conexão à internet não seria, inicialmente, responsabilizado por conteúdo de terceiros.



Exemplo

Em 2002, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2002) julgou, nos autos nº 70003736659, que o provedor de conexão não teria qualquer legitimidade para informar a origem de mensagens eletrônicas indevidas, já que serve tão somente de meio físico a interligar o usuário final ao provedor do serviço de conexão à internet.

No entanto, recentes decisões têm entendido que o provedor de conexão pode ser acionado para prestar informações sobre registro de *log* pelo período de um ano depois do fato, conforme previsão do artigo 13 do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014, documento *on-line*):

> Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.



Exemplo

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em recente decisão, entendeu que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm o dever de assegurar o armazenamento dos registros com a porta lógica de origem para posterior informação (SÃO PAULO, 2021).

Por outro lado, a Lei nº 12.965/2014 também traz previsão quanto à responsabilidade do provedor de aplicação de internet por danos causados a terceiros. O provedor de aplicações à internet, diferentemente do provedor de conexão, é aquele que oferece um conjunto de funcionalidades e ferramentas a serem acessadas por meio da internet. Os provedores de aplicação podem ser de conteúdo, de hospedagem e de correio eletrônico. São provedores de aplicação, por exemplo, Google, Hotmail, Instagram, Facebook e YouTube.

Em relação ao provedor de aplicação, o Marco Civil da Internet, em seu artigo 15º, prevê que (BRASIL, 2014, documento *on-line*):

> O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

Além disso, os provedores de aplicações poderão ser obrigados, por ordem judicial, a guardar registros de acesso a aplicações de internet por período

determinado (BRASIL, 2014, art. 15 §1º). Assim, num primeiro momento está claro que o provedor de aplicação deve guardar os registros de acesso a aplicações de internet, motivo pelo qual poderia também ser acionado para fornecê-los a usuários.

Porém, discute-se sobre a responsabilidade desses fornecedores quanto a conteúdo ilícito gerado por terceiros. Assim, se, por exemplo, um usuário de aplicativo causar dano a outro, quem deve responder? Nesse sentido, o Marco Civil da Internet dispôs em seu artigo 19 que o provedor de aplicação responderá civilmente se, após notificado judicialmente para retirada de conteúdo ilícito, não tomar providências dentro do prazo assinalado e de acordo com suas limitações para retirada do conteúdo, tornando-o indisponível.

Ademais, a ordem judicial expedida para retirada de conteúdo deve ser clara e expressa, para que permita a identificação do conteúdo apontado como infringente e a localização inequívoca do material (BRASIL, 2014, art. 19, §1º).



Fique atento

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2021a), no Recurso Especial nº 1771911, entendeu que os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar de seus sistemas os resultados de pesquisas, como algum tema, expressão, foto ou texto específico, ainda que se alegue ser ofensivo à imagem ou honra de terceiro. De acordo com o entendimento do STJ, deve haver a indicação clara e específica do conteúdo ofensivo, de modo que não poderá ser excluído genericamente pelo provedor de pesquisa.

Dessa forma, se houvesse, por exemplo, conteúdo ofensivo no Facebook contra um usuário, este poderia ingressar com ação judicial para pleitear a indisponibilidade de tal conteúdo, de forma que se o Facebook não fizesse a retirada, poderia futuramente ser responsabilizado por danos materiais e/ou morais.

Em relação a isso, o artigo 19 do Marco Civil da Internet pode ser interpretado cumulativamente à previsão do artigo 21:

> Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
> Parágrafo único. A notificação prevista no *caput* deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido. (BRASIL, 2014, documento *on-line*).

Esse caso trata-se de exceção quanto à exigência de notificação judicial: violação de direitos autorais e violação a direito de imagem de nudez ou sexo são hipóteses que determinam a exclusão do conteúdo diante de simples notificação ao provedor. Um exemplo famoso é o caso Daniella Cicarelli, em que a Google foi responsabilizado por ter publicado o vídeo da atriz no YouTube (COSTA, 2015).

Na prática, todavia, a jurisprudência também pode acrescentar hipóteses em que não seria necessária a notificação judicial do provedor de conteúdo, bastando a mera notificação ou cientificação do conteúdo inadequado para responsabilização, caso não torne indisponível o conteúdo apontado. Um caso de *bullying*, por exemplo, poderia gerar a indisponibilidade de conteúdo mediante simples notificação pessoal extrajudicial do provedor.

Assim aconteceu nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 685720 (BRASIL, 2020a, documento *on-line*), cuja decisão entendeu em 2020 que:

> [...] aos provedores de conteúdo aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para removê-la.

Por outro lado, em decisão do AREsp nº 1402112/SE, os provedores de internet não podem exercer controle prévio do conteúdo dos *sites* que hospedam, motivo pelo qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC (BRASIL, 2018).

Diante de tudo isso, podemos concluir em suma que a responsabilidade do provedor é apenas subjetiva, e não objetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa do provedor. Por isso, somente se cientificado (judicial ou extrajudicialmente) acerca do conteúdo ilícito, e não o retirando do ar, é que o provedor poderá ser responsabilizado.

Por fim, o STJ definiu recentemente acerca da responsabilidade civil quanto à relação de consumo de *sites* intermediadores, como o caso do Mercado Livre, que também são considerados provedores de aplicação. Conforme definido no REsp 1880344/SP:

> [...] a relação entre o ofertante e o intermediador será ou não de consumo a depender da natureza da atividade exercida pelo anunciante do produto ou serviço. Se o vendedor for um profissional que realiza a venda de produtos com habitualidade, ele não se enquadrará no conceito de fornecedor instituído no art. 3º do CDC, de modo que a responsabilidade civil do *site* será regida pelas normas previstas no Código Civil. Lado outro, caso o vendedor não seja um profissional e não venda produtos ou ofereça serviços de forma habitual, havendo falha na prestação de serviços por parte do intermediário, aplicam-se as normas previstas no CDC (BRASIL, 2020b, documento *on-line*).

Assim, o *site* Mercado Livre, por exemplo, ao intermediar a venda de um vendedor profissional não responderá com base no CDC (pois o próprio vendedor responderá), sendo apenas o intermediador e devendo responder com base no Código Civil. Por outro lado outro, se o responsável final pela venda não for vendedor profissional, o *site* Mercado Livre poderá responder com base no CDC.



Fique atento

Debate-se atualmente sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, com repercussão geral reconhecida, por meio do Tema nº 987 no Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2021b) quanto à necessidade obrigatória de retirada de perfil falso ou de tornar indisponível o conteúdo somente após ordem judicial específica.

Referências

BRASIL. *Código de Defesa do Consumidor e normas correlatas*. 2. ed. Brasília: Senado Federal, 2017. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/533814/cdc_e_normas_correlatas_2ed.pdf. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Agravo de Recurso Especial AREsp n. 685720/SP*. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgado em: 13 out. 2020a. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=116593888&num_registro=201500662632&data=20201016&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Agravo em Recurso Especial REsp 1880344/SP*. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em: 24 nov. 2020b. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201402661781&dt_publicacao=18/12/2020. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgInt nos EDcl no Recurso Especial n. 1402112/SE*. Relator: Ministro Lázaro Guimarães. Julgado em: 19 jun. 2018. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201202380692&dt_publicacao=26/06/2018. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial REsp 1771911/SP*. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 16 mar. 2021a. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201802611867&dt_publicacao=26/04/2021. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Tema 987*: discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. RE 1037396 RG. Brasília:

STF, 2021b. Disponível em: http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5160549&numeroProcesso=1037396&classeProcesso=RE&numeroTema=987. Acesso em: 12 jun. 2021.

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. *Convenção Americana sobre Direitos Humanos*. San José: CIDH, 1969. Disponível em: http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm. Acesso em: 12 jun. 2021.

CONVENÇÃO Americana de Direitos Humanos. San José: [*s. n.*], 1969. Ratificada em 1992. Disponível em: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm. Acesso em: 12 jun. 2021.

COSTA, C. Por que caso de Cicarelli contra Google pode ser último do tipo no Brasil. *BBC News*, 2015. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151014_google_cicarelli_cc. Acesso em: 12 jun. 2021.

GONÇALVES, V. H. P. *Marco civil da internet comentado*. São Paulo: Atlas, 2017.

GARCIA, L. A. M. *A regulamentação da internet à luz da violação à liberdade de uso*. Brasília: [*s. n.*], 2016. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/ArtigoCONPEDI2016AregulamentaodainternetluzdaviolaoliberdadedeusoIntegral.pdf. Acesso em: 12 jun. 2021.

IBGE EDUCA. Conheça o Brasil: pessoas com deficiência. Brasília: IBGE, [2021?]. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html. Acesso em: 12 jun. 2021.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. 10ª Câmara Cível. *Apelação Cível 5002175-90.2017.8.13.0439 MG*. Relator: Juiz Marcelo Pereira da Silva. Julgado em: 15 out. 2020. Disponível em: https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1114243759/apelacao-civel-ac-10000205303696001-mg/inteiro-teor-1114243784. Acesso em: 12 jun. 2021.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 10ª Câmara Cível. *Agravo de Instrumento nº 70003736659*. Relator: Des. Paulo Antônio Kretzmann. Julgado em: 9 maio 2002. Disponível em: https://www.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?numero_processo=70003736659&ano=2002&codigo=10004. Acesso em: 12 jun. 2021.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. 36ª Câmara Cível. *Registro [Autos] n. 2021.0000357353*. Relator: Pedro Baccarat. Julgado em: 11 maio 2021. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=14621607&cdForo=0. Acesso em: 12 jun. 2021.

Leituras recomendadas

BRASIL. Agência Nacional de Telecomunicações. *Norma 004/95*: uso de meios da rede pública de telecomunicações para acesso à internet. Brasília: ANATEL, 1995. Disponível em: https://www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/ANE/prt/minicom_19950531_148.pdf. Acesso em: 12 jun. 2021.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 12 jun. 2021.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.



PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

unidade
4
V.1 | 2023

Parte 3

Proteção de Dados Pessoais

O conteúdo deste livro
é disponibilizado
por SAGAH.

SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Proteção de dados pessoais

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Apresentar os fundamentos teóricos e históricos da proteção de dados pessoais
- Analisar conceitos, princípios e institutos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Definir o uso da LGPD nas áreas de educação, saúde e relações trabalhistas

Introdução

O aperfeiçoamento das discussões relativas aos dados pessoais nas últimas décadas representa a ênfase de sua relevância como direito fundamental autônomo para a tutela dos cidadãos. Com a rapidez dos avanços tecnológicos e a difusão em larga escala do acesso ao ambiente virtual, o manejo das informações sobre si próprio se tornou expressão essencial do indivíduo. Logo, torna-se impossível cogitar a integral proteção da liberdade, da privacidade e do desenvolvimento da pessoa natural sem que lhe seja garantida a eficiente defesa e o controle dos próprios dados, ou seja, a expressão da autodeterminação informativa.

Diante dos requerimentos sociais de uma nova instituição legislativa especializada na proteção dados, nasceu a denominada Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei nº 13.709 de 2018 (BRASIL, [2019]), que passou a dispor sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no ciberespaço, por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, com o intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme dispõe o artigo inaugural do documento

legal. Assim, os mais diferentes âmbitos sociais, como saúde, educação e relações de trabalho, passam a ter a necessidade de se adequar à LGPD, para um melhor desenvolvimento da sociedade e da proteção à dignidade da pessoa humana e dos preceitos trazidos na Constituição de 1988 (BRASIL, [2016]).

Neste capítulo, você vai conhecer os fundamentos teóricos e históricos da proteção de dados pessoais. Além disso, vai ver conceitos, princípios e institutos da LGPD, com destaque ao tratamento de dados e ao consentimento. Por fim, vai estudar a LGPD nas áreas da educação, saúde e relações trabalhistas.

Proteção de dados pessoais: fundamentos teóricos e históricos

Inaugurando a redação da LGPD, o artigo 1º define o alcance da proteção de dados pessoais, os quais estão vinculados tanto para o ambiente físico quanto para o digital, certificando como sujeito de direitos unicamente a pessoa natural identificada ou identificável (BRASIL, [2019]). O documento legal indica que o objetivo requerido é a proteção dos direitos fundamentais da liberdade e privacidade, além do livre desenvolvimento da pessoa natural. Finalmente, dirige-se para pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que trabalhe com dados da pessoa natural (BRASIL, [2019]).

O desenvolvimento de regulações específicas à proteção de dados também ganhou, ao longo dos anos, respaldo teórico, com atenção para preceitos advindos da Carta Maior (BRASIL, [2016]), entre eles a privacidade. O descontrole e a incerteza sobre aquele que tem o direito ao acesso aos dados pessoais perpassa o poder de escolha que delimita e define a esfera pessoal de cada ser humano. A necessidade de tutela jurídica aos que confiam seus dados pessoais às entidades públicas ou privadas se tornou evidente à medida que esses dados têm valor econômico e são usados para fins comerciais (PEZZI, 2007).

Nesse contexto, antes da edição da lei de proteção de dados, havia um debate teórico relacionado aos limites da privacidade, uma vez que os bancos de dados armazenavam — e continuam armazenando — milhões de dados pessoais, o que, na verificação da doutrina, parecia ultrapassar os direitos das pessoas em relação à gestão de seus dados. Assim, os bancos de dados se tornaram um instrumento perfeito para dilacerar os limites da privacidade. Os bancos de dados permitiam que fossem criados perfis específicos de acordo com os interesses dos titulares dos dados pessoais, e o acesso a esses bancos tomou uma dimensão ainda mais expressiva pela facilidade de transmissão

e circulação de dados. Assim, diante das relações de consumo, a criação de perfis era perfeita para a fácil e rápida transmissão de dados por meio dessas plataformas de informações pessoais. Um curso de pós-graduação, por exemplo, poderia utilizar um banco de dados de uma editora de livros especializada no segmento do curso para promover as atividades de ensino. Uma empresa de seguro de saúde poderia utilizar o banco de dados de uma loja esportiva para identificar as pessoas que, potencialmente, precisariam de serviços médicos. Uma financeira, apropriando-se de um banco de dados de uma loja de departamentos, poderia oferecer cartões de crédito a quem lhe interessasse o histórico de quitação de pagamentos para concessão da vantagem creditícia (PEZZI, 2007).

> A proporção dos reflexos possíveis com cruzamentos [de dados] se dimensiona de tal forma quando órgãos do próprio Estado tomam iniciativas para disponibilizar informações pessoais de seus cidadãos. Os jornais passam a estampar o debate sobre a possibilidade de empresas terceirizadas administrarem e comercializarem o cadastro de segurança pública do Estado de São Paulo, em troca da modernização do banco de dados. [Permitia-se ainda que] os planos de saúde [acessassem] dados sigilosos do paciente. Mesmo sendo criada para nortear o intercâmbio de dados entre os planos e os prestadores de serviço, melhorar a qualidade de gestação e coletar informações epidemiológicas necessárias para o planejamento de políticas de saúde, a medida [chocava-se] com o sigilo médico-paciente e [fornecia] um manancial de informações para o setor privado das seguradoras de saúde, [que eram capazes] de restringir [o] acesso a possíveis segurados (PEZZI, 2007, p. 11–12).

Logo, as relações de consumo, que já colocam o consumidor como figura vulnerável, passaram a ficar ainda mais instáveis por força do impacto da utilização dos bancos de dados e cadastros de consumidores sem que existisse qualquer regulamentação com embasamento específico para legislar a respeito da proteção de dados.

Foi apenas com o advento da publicação da LGPD que uma lacuna no ordenamento jurídico pátrio foi preenchida, no sentido da proteção de dados pessoais, mas normas anteriores foram precursoras desse propósito. O reconhecimento da proteção de dados como direito autônomo e fundamental advém de considerações dos riscos que o tratamento automatizado traz para a proteção da personalidade em relação às garantias constitucionais de igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, com destaque, ainda, para a proteção da intimidade e da vida privada. A proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro, embora hoje desfrute de legislação específica, ganhou respaldo em outros documentos legais (DONEDA, 2011). A Constituição Brasileira contempla a questão da informação por meio das

garantias à liberdade de expressão e do direito à informação, além de fundamentar a proteção da personalidade e o direito à privacidade (BRASIL, [2016]).

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) de 1990, documento legal que traz, em sua Seção VI, os Bancos de Dados e Cadastros dos Consumidores, garante o direito às informações existentes em relação ao consumidor (BRASIL, 1990). Nesse documento legal, destaca-se o conteúdo do artigo 43, o qual estabelece uma série de direitos e garantias para o consumidor em relação às suas informações pessoais presentes em bancos de dados e cadastros, "[...] implementando uma sistemática baseada nos *fair information principles* à matéria de concessão de crédito e possibilitando que parte da doutrina verifique neste texto legal o marco normativo dos princípios de proteção de dados pessoais no direito brasileiro" (DONEDA, 2011, p. 103). Assim:

> [Parecia] existir no direito brasileiro, de forma generalizada, uma consciência de que seria possível tratar de forma satisfatória os problemas relacionados às informações pessoais em bancos de dados a partir de uma série de categorizações, geralmente generalistas e [...] abstratas: sobre o caráter rigidamente público ou particular de uma espécie de informação; a respeito da característica sigilosa ou não de determinada comunicação, e assim por diante. Enfim: com um sistema baseado em etiquetas, permissões ou proibições para o uso de informações específicas, sem considerar os riscos objetivos potencializados pelo tratamento informatizado das informações pessoais (DONEDA, 2011, p. 104).

Outro documento jurídico especialmente importante à proteção de dados no Brasil é o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965 de 2014 (BRASIL, 2014), o qual assegura aos usuários da rede mundial de computadores a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, com destaque para o artigo 7º, incisos I a XIII, que tratam sobre direitos e garantias dos usuários, assegurando o direito às informações de forma clara e completa sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais. Além disso, o artigo 7º informa o direito do usuário ao consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais e a garantia da exclusão definitiva dos dados pessoais fornecidos a determinada aplicação de internet, a requerimento do usuário, ao término das relações entre as partes (BRASIL, 2014).

Assim, é possível perceber que, anteriormente à edição e publicação da LGPD, outros documentos legais já dissertavam, ainda que de forma discreta, sobre a necessidade da proteção de dados. Eles foram impulsionados, por exemplo, pelas revelações sobre as iniciativas de espionagem antiéticas e ilegais do governo norte-americano, como é o caso do Marco Civil da Internet (CARVALHO; OLIVEIRA, 2019).

Porém, essas iniciativas não surgiram apenas de uma preocupação do legislador brasileiro em garantir efetivas responsabilidades e sanções para entidades públicas e privadas quanto ao cuidado com o tratamento de dados. Diversos países no mundo foram impulsionados a criar legislações específicas em matéria de proteção de dados, pois escândalos de vazamento de dados passaram a influenciar processos democráticos importantes, como as eleições presidenciais estadunidenses de 2016 e o plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (BREXIT), também em 2016.

Um acontecimento notório e de grande repercussão foi o caso envolvendo a empresa Cambridge Analytica, sob a qual se especulava a relação de vendas e o uso indevido de dados na campanha eleitoral de Donald Trump em 2016. O caso veio a público pela primeira vez em dezembro de 2015 e chegou até a corte americana no início de 2018. A rede social Facebook foi responsabilizada pelo caso e penalizada ao pagamento de 5 bilhões de dólares (BISSO *et al*., 2020).

Outros exemplos práticos do vazamento de dados que foram importantes à articulação de autoridades em diversas partes do mundo para tratar os dados pessoais ocorreu com a companhia hoteleira Marriott, que foi multada em 100 milhões de libras esterlinas pelo vazamento de 339 milhões de dados de clientes. Entre esses dados, havia números de cartões de crédito e dados de passaporte. A falha foi decorrente de um sistema adotado pela empresa após a compra de outra rede de hotéis, a Starwood, que já havia sido notificada sobre problemas de segurança em seus sistemas em 2014. Outro caso ocorreu com a companhia aérea British Airways, vítima de um ataque de *hackers*, que afetou mais de 500 mil clientes em 2018. Os dados roubados incluíam o histórico de compra de passagens, informações de pagamentos e informações pessoais de seus usuários, como nome e endereço. A empresa foi responsabilizada ao pagamento de 183 milhões de libras esterlinas pelo acontecimento (BISSO *et al*., 2020).

O indiscriminado vazamento e compartilhamento de dados de forma ilegal em inúmeros casos passou a gerar impactos socioeconômicos expressivos. Segundo informações publicadas em 2018, o custo envolvendo o vazamento de dados, somente nos Estados Unidos, somou 654 bilhões de dólares e expôs 2,4 bilhões de dados de usuários (BISSO *et al*., 2020).

Diante desse cenário, governos passaram a tomar medidas para que empresas aumentassem os investimentos com a segurança dos dados dos usuários. A União Europeia criou, em 2016, uma nova regulamentação para proteção de dados pessoais: a General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) (UNIÃO EUROPEIA, 2016). Tal instrumento legal foi um importante marco para proteção e privacidade de dados dos cidadãos da União Europeia e do

Espaço Econômico Europeu. Por meio dele, a proteção de dados pessoais passou a ser tratada como direito fundamental (BISSO *et al.*, 2020).

Os Estados Unidos, por outro lado, embora inúmeras sanções sejam impostas e notadamente difundidas em relação à proteção de dados, carece de uma legislação federal que regule a matéria de forma específica. Contudo, diferente do que acontece na União Europeia com a GDPR e no Brasil com a LGPD, as leis de segurança e privacidade de dados nos Estados Unidos são específicas, regulamentando, por exemplo, o uso de determinados tipos de dados no setor de saúde, finanças e telecomunicações. Assim, objetivando tratar sobre matérias não legisladas no nível federal, algumas regulações específicas para proteção de dados estaduais são expressivamente importantes, como é o caso do estado da Califórnia, onde a matéria é regulada por meio da California Consumer Privacy Act (CCPA), e do estado de Nova York, com a New York Stop Hacks and Improve Eletronic Data Security Act (NY SHIELD) (BISSO *et al.*, 2020).

A legislação sobre proteção de dados brasileira foi notadamente inspirada no regulamento da União Europeia, a GDPR, que entrou em vigor em 2018 e trouxe importantes impactos para empresas e consumidores. Com isso, o Brasil, com o advento da LGPD, que entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, passou a compor um grupo de países que contam com legislação específica para a proteção de dados de seus cidadãos. Assim, diante dos atuais casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados, as novas regras passaram a garantir a privacidade dos titulares dos dados pessoais, além de passar a evitar entraves comerciais com outros países (MOTA; TENA, 2020).



Saiba mais

Stefano Rodotà (2008), no livro *A vida na sociedade da vigilância*, afirma que:

> [...] não se faz mais possível considerar os problemas de privacidade somente por meio de um pêndulo entre "recolhimento" e "divulgação"; entre o homem prisioneiro de seus segredos e o homem que nada tem a esconder; entre a "casa fortaleza", que glorifica a privacidade e favorece o egocentrismo, e a "casa-vitrine", que privilegia as trocas sociais; e assim por diante. Essas tendem a ser alternativas cada vez mais abstratas, visto que nelas se reflete uma forma de encarar a privacidade que negligencia justamente a necessidade de dilatar esse conceito para além de sua dimensão estritamente individualista, no âmbito da qual sempre esteve confinada pelas circunstâncias de sua origem (RODOTÀ, 2008, p. 25).

Conceitos, princípios e institutos da LGPD

A LGPD foi sancionada pensando que todo dado pessoal tem relevância e valor. Por tal razão, o conceito de dado pessoal ganhou amplitude, assim como na GDPR, no sentido de que os dados pessoais são equivalentes a informações relativas à pessoa singular identificada ou identificável, conforme preceitua o artigo 5º, I da LGPD (BRASIL, [2019]). Assim, mesmo que determinados dados pareçam não ter relevância em dado momento ou que não façam a direta referência a uma determinada pessoa, quando são transferidos, cruzados ou organizados, têm a possibilidade de resultar em dados específicos em relação a uma determinada pessoa. Eles podem carregar informações de caráter sensível sobre ela, como foi observado pelo Tribunal Constitucional Alemão no julgamento sobre a Lei do Censo em 1983 (MARTINS, 2016).

Assim, pela cautela de tratamento da matéria, a regra estabelecida pela LGPD, em seu artigo 1º, é a de que qualquer pessoa que trate de dados, seja ela natural ou jurídica, de direito público ou privado, inclusive na atividade realizada por meios eletrônicos, deverá ter um arquétipo legal para fundamentar os tratamentos de dados pessoais que realizar (BRASIL, [2019]). Portanto, não haverá necessidade de identificação de uma base legal específica apenas nos casos enquadrados nas hipóteses de exclusão da aplicação da LGPD, conforme o disposto no artigo 4º (BRASIL, [2019]). Contudo, da mesma forma, o tratamento de dados pessoais (previsto no artigo 4º, III), ou seja, aqueles para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, "[...] será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observando o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular" (BRASIL, [2019], documento *on-line*). Assim, foi estabelecida, junto à Câmara dos Deputados, uma comissão de especialistas judiciais responsáveis pela elaboração de um anteprojeto de lei em relação à matéria. Logo, quando não cabe possibilidade de exclusão, o tratamento deverá ser adaptado e realizado em pelo menos uma das hipóteses legais, para que ele seja considerado legítimo e lícito. Tais bases foram determinadas de forma genérica, e as adequações devem ser realizadas por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo (TEFFÉ; VIOLA, 2020).

É fundamental ressaltar que a LGPD no Brasil disciplina os dados por meio de fundamentos que se balizam no respeito à privacidade, na autodeterminação informativa, na liberdade de expressão, informação, de comunicação

e de opinião, na inviolabilidade da honra, da intimidade e da imagem, no desenvolvimento econômico e tecnológico, na livre iniciativa e na livre concorrência e a partir da defesa do consumidor e, de acordo com os direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade e pela igualdade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais, conforme a extração do artigo 2º, incisos I a VII, da LGPD (BRASIL, [2019]).

Vale observar que, com o advento da LGPG, uma série de conceitos foi delineada de maneira expressa, como o que acontece na definição de dados pessoais e dados sensíveis, os quais, por previsão legais, recebem tratamentos diferentes e têm determinações legislativas particulares. O artigo 5º, I, conceitua **dado pessoal** como a informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, enquanto os **dados sensíveis** são aqueles relacionados a dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, além dos dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico (quando vinculado a uma pessoa natural, disposição prevista no artigo 5º, II (BRASIL, [2019]). A lei ainda traz considerações a respeito do conceito de:

> [...] dado anonimizado [...]; banco de dados [...]; titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador (BRASIL, [2019], documento *on-line*).

A base da LGPD é desenvolvida a partir da concepção de princípios e da observância da boa-fé, que regem as atividades de tratamento de dados pessoais. Por meio dos princípios que norteiam a base legal da proteção de dados, é possível compreender as condições e circunstâncias pelas quais ela vai ser aplicada, especialmente pelo fato de que os princípios funcionam como uma bússola que norteará as interpretações dos tribunais nos casos em que questões sejam aludidas e não possuam respaldo expresso no dispositivo de lei. Nesse sentido, "[...] princípio é toda norma jurídica considerada determinante de outra ou outras que lhe são subordinadas que a pressupõe, desenvolvendo e especificando o preceito em direções mais particulares" (VAINZOF, 2019, p. 136).

Assim, os princípios gerais da proteção de dados foram elaborados e expressamente previstos em lei, devendo ser interpretados em benefício do titular de dados.

> Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
> I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
> II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
> III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
> IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
> V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
> VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
> VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
> VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
> IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
> X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas (BRASIL, [2019], documento *on-line*).

Logo, por meio do **princípio da finalidade**, o titular pode garantir a legalidade do seu processamento de dados (por meio das informações obtidas previamente, limitando a finalidade do processamento) e de terceiros, podendo ou não acessar os dado e, reduzindo, assim, o risco do uso secundário dos dados sem o consentimento do titular (VAINZOF, 2019).

O **princípio da adequação** prevê que o tratamento de dados pessoais "[...] somente pode ser realizado quando houver compatibilidade com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento" (VAINZOF, 2019, p. 142).

A **necessidade**, como princípio previsto da LGPD, determina "[...] a limitação do tratamento aos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade do tratamento" (LOUZADA, 2019, p. 96).

Por meio do **princípio do livre acesso**, permite-se que o titular do dado acompanhe o fluxo informacional do dado, tendo o direito de descarte em

casos de dados incorretos, desatualizados, fora de contexto ou de caráter ilícito (MACHADO; MARCONI, 2020).

O **princípio da qualidade** funciona como um instrumento de impedimento de injustiças, pois estabelece a necessidade de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados (LOUZADA, 2019).

O **princípio da transparência** é entendível como fonte essencial para se atingir o objetivo do instrumento legal de proteção de dados: proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Sem o simples acesso às informações de forma clara e precisa em relação ao tratamento dos dados, não há como garantir ao titular a tutela da transparência (VAINZOF, 2019).

Sabidamente, o **princípio da segurança** "[...] tem relevância especial porque, em sua essência, sem segurança forte, não pode haver privacidade" (BRASIL, 2020, p. 52). Logo, a centralidade desse princípio está na manutenção dos dados da pessoa física em ambiente seguro.

O **princípio da prevenção** deve estar calcado no conceito de *privacy by design*, o qual vem sendo reconhecido mundialmente "[...] como valioso auxílio para o cumprimento de exigências legais sobre privacidade de dados, considerando que são diretrizes gerais que devem nortear o processo de adequação específica de cada empresa" (VAINZOF, 2019, p. 158).

O tratamento de dados não pode ser realizado para **fins discriminatórios** ilícitos ou abusivos.

> Não se pode ter exclusão de titulares de dados pessoais no momento de seu tratamento de dados pessoais por determinadas características, sejam elas de origem racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, geolocalização, filiação sindical, saúde ou orientação sexual (MACHADO; MARCONI, 2020, p. 2611).

Finalmente, por meio do **princípio da responsabilização e prestação**, a LGPD demonstrou aos controladores e aos operadores de dados que eles são responsáveis por todas as medidas que forem adotadas com o objetivo de atender a exigências legais e de princípios estabelecidos em lei (VAINZOF, 2019).

Os princípios previstos na LGPD, ainda que fracionados, condensados ou adaptados, formam a centralidade de diversas leis, tratados, convenções ou acordos de proteção de dados pessoais. Juntos, formam o núcleo das questões com as quais o ordenamento deve se deparar ao procurar fornecer sua própria solução ao problema da proteção dos dados pessoais (DONEDA, 2011).

Outra questão de extrema importância extraída da LGPD é o tratamento dos dados pessoais e dos dados sensíveis, expressamente previstos na lei de proteção de dados brasileira. Compreende-se que, tanto o rol do artigo 7º, que prevê o tratamento dos dados pessoais, quanto o do artigo 11, que

dispõe sobre o tratamento de dados sensíveis (BRASIL, [2019]), são taxativos, embora sejam dotados de hipóteses mais abertas e com relativo grau de subjetividade, como o legítimo interesse (TEFFÉ; VIOLA, 2020).

> De forma a se evitar abusos no tratamento de dados e garantir os direitos do titular, ele poderá revogar o seu consentimento, [...] ou pleitear o direito à oposição, que significa que o titular poderá se opor a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto na LGPD (Art. 18, §2º). Além disso, encontra-se positivado o direito à explicação (Art. 20), que dispõe que o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade (TEFFÉ; VIOLA, 2020, p. 4-5).

O sistema legal que foi desenvolvido para o tratamento de dados confere ao titular instrumento de controle em relação as suas informações pessoais e de garantia de direitos, com especial destaque para o consentimento e o legítimo interesse. O consentimento simboliza "[...] instrumento de manifestação individual no campo dos direitos da personalidade e tem o papel de legitimar que terceiros utilizem, em alguma medida, os dados de seu titular" (TEFFÉ; VIOLA, 2020, p. 7). É por meio do consentimento que se realiza a promoção da personalidade, representando uma modalidade para a edificação e determinação da esfera privada. Ele vincula-se, então, à autodeterminação existencial e informacional do ser humano, se apresentando como fundamental para a proteção do titular dos dados e, da mesma forma, para o fluxo de informações (DONEDA, 2011).

A LGPD, na disposição do artigo 5º, XII, prevê o consentimento como a "[...] manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada" (BRASIL, [2019], documento *on-line*). Com relação ao consentimento requerido e ao consentimento necessário, Teffé e Viola (2020, p. 10) afirmam:

> Na hipótese em que o consentimento é requerido, ele será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Quando o consentimento for necessário, havendo mudanças em relação à finalidade para o tratamento dos dados não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo este revogar o consentimento, caso discorde das alterações.

Assim, a LGPD procura, seja pelo consentimento, seja pelo tratamento de dados ou por tantos outros instrumentos dispostos expressamente na

legislação, implementar mecanismos para a proteção e garantia da dignidade humana. Assim, a lei de proteção de dados, além de facilitar o controle dos dados tratados, impõe responsabilidades aos agentes de tratamento e oportuniza segurança para que as informações sejam transmitidas. A lei objetiva avançar os riscos de violação à privacidade e impede intervenções abusivas de informações e vazamento de dados (TEFFÉ; VIOLA, 2020).



Saiba mais

O estudo "Direito fundamental à liberdade de pesquisa genética e à proteção de dados pessoais: os princípios da prevenção e da precaução como garantia do direito à vida privada", de Regina Linden Ruaro (2015), analisou os direitos fundamentais de liberdade de pesquisa e da proteção de dados pessoais no âmbito da genética humana e propôs a aplicação dos princípios de precaução e da prevenção. A partir desse trabalho, foi realizada uma avaliação da legislação brasileira como medida de garantia à privacidade dos dados pessoais e das informações colhidas na investigação científica. O estudo queria elucidar a limitação de direitos fundamentais a partir da concepção de que eles não são absolutos. Foi proposta, ainda, a aplicação dos princípios da precaução e da prevenção no ciberespaço.

LGPD nas áreas de educação, saúde e relações trabalhistas

O artigo 5º, inciso II, da LGPD, traz importantes e sensíveis desdobramentos dos dados pessoais (BRASIL, [2019]). Entre eles, estão os dados vinculados com saúde, também denominados de dados clínicos ou informações médicas. Por seu elevado potencial discriminatório e lesivo, os dados que contêm informações de saúde impulsionam a imprescindibilidade de preservação e proteção, para que sejam garantidos os direitos à dignidade, ao sigilo e à vida privada dos titulares (BRASIL, [2019]).

Pelo elevado grau de lesividade dos dados sensíveis (por revelarem informações de caráter personalíssimo, embutidas no âmbito da proteção do direito de personalidade), sua coleta, processamento e tratamento devem acontecer apenas após o consentimento expresso do titular, uma vez que a inobservância da anuência viola a legislação de proteção de dados, com destaque para os dados confidenciais e as reservas do ser (SIQUEIRA; HOCH, 2019).

> Há construção teórica e legislativa, no plano internacional, que fomenta a utilização do referencial de "direitos humanos dos pacientes" (DHP), previstos em documentos elaborados e adotados no âmbito de organizações e sistemas internacionais, como

> ferramenta para análise de imbróglios éticos que exsurgem na área da saúde. São considerados direitos humanos aplicáveis ao contexto dos cuidados em saúde e de pacientes o direito à vida, o direito a não ser submetido a tratamento desumano, degradante, cruel ou à tortura, o direito à liberdade e segurança pessoal, o direito à saúde integral, o direito de não sofrer discriminação de qualquer tipo, e, especialmente relevante ao presente propósito, o direito à informação e ao respeito à vida privada. Pode-se afirmar, assim, a partir da abordagem exposta, que os dados médicos revelam-se como importante ramificação dos dados pessoais e consistem em informações sensíveis de saúde depositadas em hospitais, após internações ou cirurgias, em laboratórios, após a coleta de exames, em clínicas, após a realização de procedimentos, em consultórios médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, psicológicos ou psiquiátricos, após a realização de consultas e sessões, ou até mesmo em cadastros de planos de saúde, após a solicitação de autorização para realização de exames ou procedimentos. Além dos dados de saúde, os registros dos pacientes em citados estabelecimentos contêm inúmeras informações de cunho pessoal, incluindo nomes, datas de nascimento, endereços, números de seguro e de planos de saúde de cada indivíduo (SIQUEIRA; HOCH, 2019, p. 8).

Assim, pelo potencial interesse na coleta de dados de saúde dos titulares, não apenas por seguradoras e planos de saúde, mas também por *hackers* e estelionatários, é necessário que a participação do detentor dos dados seja efetiva. Nesse sentido, a autodeterminação informativa do paciente (fundamento essencial da LGPD) deve ser protegida a partir dos preceitos trazidos no artigo 2º, II (BRASIL, [2019]), inaugurando-se com o preenchimento do termo de consentimento esclarecido e informado, instrumento necessário tanto para a realização de uma consulta médica quanto para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Os termos de consentimento devem "[...] conter avisos claros relativos ao grau de confiabilidade de exames, alertas de possíveis riscos, consequências fisiológicas e complicações, além do caráter, objetivos e benefícios da intervenção" (SIQUEIRA; HOCH, 2019, p. 10). Eles também devem conter linguagem simples, para que a compreensão do paciente seja completa, autônoma e consciente durante o ato de anuência ou rejeição.

Entretanto, como se trata de dado sensível, o consentimento tem expressiva importância diante dos dados médico. São escassos os termos de consentimento que advertem o paciente em relação ao uso, destino e armazenamento dos dados de saúde, o que coloca em risco o direito à privacidade e à intimidade do indivíduo.

Por outro lado, vale destacar a interferência que a publicação da LGPD trouxe para as relações trabalhistas. Embora não haja qualquer menção na lei de proteção quanto às questões que vinculam o direito do trabalho por seus dispositivos relacionados ao tratamento de dados pessoais e sensíveis, é possível se depreender que, de forma fática, aplica-se o artigo 1º, bem como

o artigo 5º, da LGPD (BRASIL, [2019]) às relações de trabalho, regulamentadas por meio da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) (BRASIL, [2017]).

Assim, da análise conjunta da LGPD e da CLT, retira-se que o empregador se enquadra como agente controlador dos dados de seus funcionários, de candidatos às vagas de emprego e de funcionários desligados. Para os fins da LGPD, os dados manipulados por empregadores são compatíveis com os previstos no artigo 5º, X, da legislação de proteção de dados nacionais (BRASIL, [2019]).

> X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração (BRASIL, [2019], documento *on-line*).

Por outro lado, funcionários, candidatos às vagas de emprego e funcionários desligados são denominados titulares dos dados e detêm dados pessoais e sensíveis, como informações sobre associação a sindicatos.

> Há um intenso fluxo de "Dados Pessoais", tal qual definido na LGPD, envolvendo o contrato de trabalho, diretamente entre o Empregado-Titular e o Empregador-Controlador/Operador, desde (a) as fases anteriores à sua celebração (informações sobre o candidato, currículo, histórico, etc.), passando (b) pela celebração do contrato de trabalho (dados cadastrais, filiação a sindicado, endereço, nomes dos genitores, escolaridade, situação familiar, nomes dos filhos, idade, tipo sanguíneo etc.), e ainda (c) durante a execução do contrato de trabalho (jornada de trabalho, valor do salário, descontos, faltas, motivos das faltas, doenças, acidentes, situações conjugais que podem ter reflexos em providências da empresa, como o pagamento de pensão, inclusão de um dependente no plano de saúde, etc.), e por fim (d) ao término do contrato de trabalho (motivo do desligamento, valor das verbas rescisórias, etc.) (OLIVIERI, 2019, documento *on-line*).

Nesse caso, em que o empregado é o titular dos dados e o empregador é o controlador (uma vez que realiza o tratamento de dados fornecidos em razão do contrato de trabalho), a LGPD é aplicável para as relações de trabalho, sendo de responsabilidade do empregador verificar as regras relativas à proteção de dados pessoais de seus funcionários e aplicar medidas de segurança, técnicas e administrativas para a proteção dos dados, conforme a previsão do artigo 46 da LGPD, aplicável desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução (BRASIL, [2019]). Assim, por meio de uma interpretação extensiva, visto que se trata de norma de proteção, o empregador deve tratar adequadamente as informações dos funcionários na pré-contratual, na fase

contratual e na fase pós-contratual, por exemplo, por meio do cuidado com o termo de rescisão de contrato de trabalho (TORRES; CALCINI, 2020).

É importante destacar que, por força da LGPD, o empregador passa a ter a obrigação de informar ao titular do dado sobre a forma de tratamento desses dados, observando os princípios da licitude, lealdade e transparência, além dos previstos expressamente na lei de proteção de dados pessoais. Além disso, para a realização de tratamento lícito, o titular dos dados pessoais sensíveis deve emitir seu consentimento para as finalidades a que são propostas (GRECO, 2020).

É possível analisar também a relação entre a LGPD e a educação. Assim como nos casos das relações de trabalho e dos dados vinculados à saúde, também é necessária a adaptação dos ambientes de ensino à LGPD. Porém, o destaque especial à área da educação está no tratamento dos dados previstos no artigo 14 da LGPD, que indica o controle do tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes por todas as instituições que, de alguma forma, colhem informações de menores (PINHEIRO, 2020).

O risco está no fato de que a exposição ou o vazamento de dados de menores é expressivo, uma vez que, cada vez mais cedo, os indivíduos têm acesso aos recursos digitais, seja para questões pessoais, seja como recursos de ensino e aprendizagem (PINHEIRO, 2020). Em tempos de pandemia, isso está ainda mais acentuado, pois as escolas estão fechadas e os alunos estão recebendo tratamento escolar *on-line*.

Assim, os controladores, que na educação representam majoritariamente as instituições de ensino, devem observar o que indica a LGPD em relação ao consentimento, que deve ser fornecido por um dos pais ou pelo responsável legal da criança ou do adolescente (PINHEIRO, 2020). Caso não o fizer, o controlador fica sujeito às sanções previstas na lei de proteção de dados: multas que variam de 2% do faturamento até R$ 50 milhões (BRASIL, [2019]).

> Mesmo em casos específicos, em que a instituição precise contatar os pais ou representantes legais, se não tiver o consentimento ainda, esses dados coletados só poderão ser usados para essa ação pontual, e apenas uma única vez, não sendo permitido armazená-los. Além dos dados pessoais, que identificam a criança ou o adolescente, como nome completo, dados dos pais, endereço, entre outros, há os dados sensíveis, que incluem religião, origem racial ou étnica e até informações sobre saúde, que não estão de fora das exigências tratadas na LGPD. Portanto, no caso escolar, os relatórios pedagógicos sobre o rendimento do aluno têm muitas informações que se enquadram na categoria de dados sensíveis (PINHEIRO, 2020, documento *on-line*).

Devem se adequar à LGPD, sob pena de recebimento de sanções, creches, escolas, universidades e mantenedoras sociais ou religiosas, incluindo fornecedores que atuam em conjunto com elas, como o transporte escolar, os responsáveis por passeios e excursões e até mesmo o teatro, o museu, o cinema e os ambientes que realizam atividades esportivas (PINHEIRO, 2020).

Na educação, deve-se realizar o equilíbrio entre os dados necessários, a forma de tratamento deles e tudo o que é trazido pela conveniência e pelo instrumento legal em vigor no território nacional. É importante destacar alguns pontos importantes à educação. O primeiro deles é a atualização de contratos de matrícula, que agora passam a contemplar uma demonstração clara de quais dados são coletados, onde são armazenados, por quanto tempo esse armazenamento acontecerá, quem terá acesso aos dados e qual é a finalidade de sua utilização. Para atender à LGPD, em especial ao seu artigo 14, os alunos devem ser separados por idade, a fim de verificar a necessidade de consentimento para o tratamento dos dados (BRASIL, [2019]). Por fim, investimentos em segurança de dados na educação passam a ser imprescindíveis, assim como o amparo legal para cada dado coletado, mantendo sempre uma comunicação clara com os usuários e seus pais ou responsáveis legais. Professores, secretários, diretores, gestores, reitores e todos os outros profissionais vinculados à área da educação devem passar por um treinamento adequado, para conhecer as implicações da LGPD na educação.



Exemplo

Leia os textos “Impactos da Lei de Proteção de Dados (LGPD) brasileira no uso da Computação em Nuvem”, de Márcio Aurélio de Souza Fernandes *et al*. (2021), e “LGPD: o que a condenação da Cyrela por uso indevido de dados deixa de alerta”, de Carlos Eduardo Vasconcellos (2020), para conferir exemplos que envolvem a LGPD.

Referências

BISSO, R. *et al*. Vazamento de dados: histórico, impacto socioeconômico e as novas leis de proteção de dados. *ReABTIC - Revista Eletrônica Argentina-Brasil de Tecnologias da* Informação e da Comunicação, v. 3, n. 1, 2020. Disponível em: https://revistas.setrem.com.br/index.php/reabtic/article/view/378/174. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. Comitê Central de Governança de Dados. *Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)*: guia de boas práticas para implementação na administração pública federal. Brasília: Comitê Central de Governança de Dados, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaLGPD.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. *Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943*. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília: Presidência da República, [2017]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. *Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990*. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. *Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014*. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres do uso da Internet no Brasil. Brasília: Presidência da República, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.

BRASIL. *Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.

CARVALHO, L. P.; OLIVEIRA, J. Proteção de dados e humanidades digitais no Brasil: caixas-pretas. *Revista Scientiarum Historia XII*, v. 1, n. 1, p. 1-9, 2019. Disponível em: http://revistas.hcte.ufrj.br/index.php/RevistaSH/article/view/32/28. Acesso em: 19 abr. 2021.

DONEDA, D. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. *Espaço Jurídico*, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011. Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/1315/658. Acesso em: 19 abr. 2021.

FERNANDES, M. A. S. *et al*. Impactos da Lei de Proteção de Dados (LGPD) brasileira no uso da computação em nuvem. *RISTI — Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, n. e42, p. 374-385, fev. 2021.

GRECO, E. *Os impactos da LGPD nas relações de trabalho*. Law Innovation, 2020. Disponível em: https://lawinnovation.com.br/os-impactos-da-lgpd-nas-relacoes-de-trabalho/. Acesso em: 19 abr. 2021.

LOUZADA, L. Princípios da LGPD e os bancos de perfis genéticos: instrumentalizando a garantia de direito no processo penal. *Revista do Advogado*, v. 39, n. 144, p. 90-98, nov. 2019.

MACHADO, L. C. P.; MARCONI, L. P. Estudos preliminares sobre os princípios aplicados ao tratamento de dados pessoais na Lei n. 13.709/2018 - LGPD. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 25., 2020, Presidente Prudente. *Anais* [...]. Presidente Prudente: ENEPE/Unoeste, 2020.

MARTINS. L. *Tribunal Constitucional Federal Alemão*: decisões anotadas sobre direitos fundamentais. São Paulo: Konrad-Adenauer Stiftung – KAS, 2016. v. 1: Dignidade humana. Livre desenvolvimento da personalidade, direito fundamental à vida e à integridade física e igualdade.

MOTA, I. D.; TENA, L. P. Fundamentos da LGPD: círculos concêntricos e sociedade de informação no contexto de direitos da personalidade. *Revista Jurídica*, v. 2, n. 59, p. 538-576, 2020. Disponível em: http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/download/4330/371372603. Acesso em: 19 abr. 2021.

OLIVIERI, N. *Rotinas e contratos de trabalho serão impactados pela LGPD?* Serpro, 2019. Disponível em: https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/impactos-lgpd-rotinas-trabalhistas-contrato-de-trabalho. Acesso em: 19 abr. 2021.

PEZZI, A. P. J. *A necessidade de proteção dos dados pessoais nos arquivos de consumo*: em busca da concretização do direito à privacidade. 2007. 215 f. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/2400/necessidade%20de%20protecao.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 19 abr. 2021.

PINHEIRO, P. P. *A LGPD aplicada ao cenário da educação*. Serpro, 2020. Disponível em: https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/educacao-lgpd. Acesso em: 19 abr. 2021.

SIQUEIRA, L. S.; HOCH, P. A. Os dados pessoais e a proteção de dados de saúde: análise a partir das iniciativas de e-saúde. *In*: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, 5., 2019, Santa Maria. *Anais* [...]. Santa Maria: UFSM, 2019. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2019/09/5.2.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021.

TEFFÉ, C. S.; VIOLA, M. Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais. *Civilistica.com*, v. 9, n. 1, p. 1-38, 2020. Disponível em: https://civilistica.com/wp-content/uploads1/2020/05/Teff%C3%A9-e-Viola-civilistica.com-a.9.n.1.2020-2.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021.

TORRES, L.; CALCINI, R. Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. *Migalhas*, 18 ago. 2020. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/332108/os-impactos-da-lei-geral-de-protecao-dedados-nas-relacoes-de-trabalho. Acesso em: 19 abr. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). *Jornal Oficial da União Europeia*, 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT. Acesso em: 19 abr. 2021.

VAINZOF, R. Disposições preliminares. *In*: MALDONADO, V. N.; BLUM, R. O. (coord.). *LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Comentada*. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

VASCONCELLOS, C. E. *LGPD*: o que a condenação da Cyrela por uso indevido de dados deixa de alerta. O Consumerista, 2020. Disponível em: https://www.oconsumerista.com.br/2020/10/lgpd-o-que-a-condenacao-da-cyrela-deixa-de-alerta/. Acesso em: 19 abr. 2021.

Leituras recomendadas

RODOTÀ, S. *A vida na sociedade da vigilância*: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

RUARO, R. L. Direito fundamental à liberdade de pesquisa genética e à proteção de dados pessoais: os princípios da prevenção e da precaução como garantia do direito à vida privada. *Revista do Direito Público*, v. 10, n. 2, p. 9-38, maio/ago. 2015. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/download/22298/16895. Acesso em: 19 abr. 2021.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

PREZADO ESTUDANTE

ENCERRA AQUI O TRECHO DO LIVRO DISPONIBILIZADO PELA SAGAH PARA ESTA PARTE DA UNIDADE.

CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é evoluir.

Av. Victor Barreto, 2288 | Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br